

RECURSO CÍVEL Nº 5093623-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RICARDO ROCHA DE ASSIS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IRPF SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E RECONHECIMENTO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. LEI Nº 13.467/17 DISPÕE SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA) E TEMA 306 TNU. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRECEDENTE Nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre o Adicional Hora Repouso e Alimentação (AHRA), condenando a União a restituir o que foi retido desse imposto, observada a prescrição quinquenal. Juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Sem custas e honorário, por se tratar de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/1995). Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5093623-24.2024.4.02.5101

510015373842 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5093623-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RICARDO ROCHA DE ASSIS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de improcedência do pedido de declaração da não-incidência do imposto de renda sobre a verba salarial Adicional Hora Repouso Alimentação - AHRA, além da condenação para restituir o que foi descontado.

Segue a sentença:

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

RICARDO ROCHA DE ASSIS propôs ação, sob o rito do Juizado Especial Federal, em face de **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a restituição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda, calculados sobre Adicional Hora de Repouso e Alimentação - AHRA.

Contestação no evento 6.1.

Quanto à prescrição, tem-se que o prazo prescricional para a restituição de indébito inicia-se a partir do pagamento da exação, nos termos do art. 168, I c/c art. 156, I, do CTN, restando prescritas as parcelas recolhidas há mais de cinco anos da propositura da ação, anteriores a 14/11/2019.

*No mérito, acompanho entendimento que "Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, **é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte.**" Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, em 09/05/2007; EREsp*

670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5". (EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008).

A meu sentir o pagamento das verbas em foco não guarda distinção para com aquelas destinadas a **remunerar horas extras** de trabalho e, neste caso, "A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. **Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber:** EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. (STJ, RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Para além disto, a matéria não demanda maiores digressões sobre a **natureza remuneratória** da verba denominada "HRA - Hora Repouso Alimentação", posto que o tema já se pacificou junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a **verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória**, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: EREsp n. 1.619.117/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020; AgInt nos EAREsp n. 1.122.223/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020.; AgInt no AREsp n. 1.832.700/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.122.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018; e AgRg no REsp n. 1.449.331/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016". (AgInt no AREsp n. 2.018.433/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Cabe destacar que "A **alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º** da CLT **não tem o condão de modificar** o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021)". (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.).

Logo, a improcedência do pedido se impõe.

Do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.**

Recurso inominado no evento 16. Alega a parte autora que a não-incidência do imposto de renda sobre a verba AHRA foi declarada em sede de PUIL.

VOTO

A temática em exame foi apreciada por esta 8ª Turma Recursal em sessão realizada em 18/08/2020 (Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ, de relatoria do Dr. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA). Segue trecho do julgamento:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA SOBRE ELA, CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

A CLT prevê no artigo 71 que quando o período para repouso e alimentação não for concedido, a empresa tem de remunerar o funcionário pelo tempo correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

A problemática reside em saber qual a natureza dos pagamentos: se esta é indenizatória ou remuneratória. No primeiro caso, não há tributação, já que não se trata de salário. No segundo caso, deverá haver tributação.

Pois bem, quanto ao tema o STJ já havia firmado entendimento de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídos tem sua natureza salarial e incidem sobre elas a tributação, nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017.

Assim, não possuindo natureza indenizatória, mas salarial, é possível a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda, em princípio.

Quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento,

de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.

CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017.

(EREsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020)

Todavia, como ressaltado no julgado acima, a Lei nº 13.467/2017, no artigo 71, § 4º trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)**

§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. **(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)**

Assim, **não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17.**

No entanto, a par da modificação introduzida pela legislação trabalhista entende-se que a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, configurando retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991.

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Tema 20. RE 565.160. Salário-maternidade. Salário-paternidade. Férias usufruídas. Horas extras. Adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade. Atestados médicos/faltas justificadas. Auxílio-alimentação (em pecúnia). Repouso semanal remunerado e feriados. Intrajornada. Décimo terceiro salário. Salário família. Abono de férias. Auxílio educação. Auxílio casamento e auxílio funeral. Auxílio-creche. Abono de faltas. Abono assiduidade. Adicional de transferência. Férias usufruídas. Adicional constitucional sobre férias gozadas. Primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Aviso prévio indenizado. [...] 4. **Incide contribuição previdenciária sobre salário maternidade, salário-paternidade, férias usufruídas, horas extras, adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade, atestados médicos/faltas justificadas, auxílio-alimentação (em pecúnia), repouso semanal remunerado e feriados, intrajornada, décimo terceiro salário, abono de faltas, adicional de transferência.** (TRF4 5003384-65.2014.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 19/12/2017)

Com efeito, a referida rubrica será incorporada aos proventos de aposentadoria, já que faz parte do seu cálculo, mesmo na legislação atual."

No mesmo sentido é o Tema 306 da TNU:

Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como **Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)**, em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), **não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.**

Uma vez que a sentença foi proferida em harmonia com o entendimento acima referido, o recurso deve ser improvido.

A despeito da alegação da União sobre a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 306, não houve determinação de suspensão de julgamentos dos processos com a mesma temática, destacando que a questão em debate será novamente apreciada em razão do PUIL/STJ n. 3742, de modo que nada obsta a aplicação do referido Tema, o que tampouco inviabilizará a hipótese de retratação pela Turma da decisão ora proferida, se assim decidir a Corte Superior.

Não há o que acolher no recurso. A sentença é clara, devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos acima expendidos.

Por fim, em sede de cumprimento de sentença, nada obsta que a União apresente cálculo do valor devido, recalculando o imposto de renda do ano calendário.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre o Adicional Hora Repouso e Alimentação (AHRA), condenando a União a restituir o que foi retido desse imposto, observada a prescrição quinquenal. Juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Sem custas e honorário, por se tratar de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/1995). Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.